

1500495-16.2020.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: GUSTAVO HENRICHS FAVERO

Comarca: Cubatão

Foro: Foro de Cubatão

Vara: 4ª Vara

Data de Disponibilização: 08/11/2022

... em localidade conhecida como zona de tráfico. Visualizaram o Réu e outro indivíduo, Alex, adentrando um bar e fechando as portas de aço. Realizaram o cerco do bar e adentraram. Foram abordados Matheus, Alex e o dono do Bar. Matheus e Alex estavam juntos. O local é conhecido como zona de tráfico, por isso o motivo da operação. Matheus e Alex, ao visualizarem a viatura, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cubatão

Foro de Cubatão

4ª Vara

Avenida Joaquim Miguel Couto, 320, Cubatão-SP - cep 11500-001

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500495-16.2020.8.26.0536 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500495-16.2020.8.26.0536

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2039487/2020 - 03º D.P. CUBATÃO, 9970516 - 03º D.P. CUBATÃO, 114/20/231 - 03º D.P.

CUBATÃO, 2039487 - 03º D.P. CUBATÃO, 114/20/231 - 03º D.P. CUBATÃO

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

MATHEUS VICTOR XAVIER DA SILVA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUSTAVO HENRICHS FAVERO

I - RELATÓRIO

MATHEUS VICTOR XAVIER DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado por infração ao artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/2006.

Isto porque, segundo a denúncia, no dia 11 de fevereiro de 2020, por volta das 17h40, no Caminho Santa Bárbara, nº 148, Vila Esperança, Cubatão, MATHEUS VICTOR XAVIER DA SILVA, qualificado a fls. 16, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, substâncias entorpecentes, "crack" e cocaína, causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e de apreensão de fls. 08/09 e auto de constatação provisória de fls. 24/25. Segundo o narrado, na data e local dos fatos,

durante operação, policiais militares visualizaram um indivíduo portando uma sacola, em atitude suspeita. Ao perceber, então, a presença dos milicianos, empreendeu fuga, adentrando em um bar. Ato contínuo, os policiais desembarcaram da viatura, iniciaram a perseguição, ingressaram no estabelecimento e se depararam com o indivíduo supramencionado, ora denunciado, além da sacola, a qual portava, em cima de uma mesa. Verificado o conteúdo no interior da sacola, lograram êxito em localizar 231 (duzentos e trinta e um) invólucros de pedras de "crack", pesando aproximadamente 68 gramas, 01 (uma) porção de pedra de "crack", pesando cerca de 78 gramas, e um saco de cocaína a granel, pesando por volta de 256 gramas, além da quantia de R\$ 17,00, em espécie. A razoável quantidade e variedade dos entorpecentes encontrados, o modo de acondicionamento, as circunstâncias da apreensão e os testemunhos dos policiais, demonstram que o denunciado praticava o tráfico ilícito de entorpecentes, segundo a denúncia.

A denúncia foi recebida em 06 de março de 2020 (fls. 103).

O acusado foi citado e apresentou defesa prévia (fls. 122/123). Juntada sua folha de antecedentes em fls. 62/63.

Em audiência de instrução realizada, foram inquiridas as testemunhas arroladas pela acusação e defesa. Ao final, o réu foi interrogado.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público pleiteou a absolvição do acusado.

A defesa, por seu turno, postulou a absolvição por insuficiência probatória.

Subsidiariamente, a desclassificação para a figura do art. 28, aplicação do parágrafo 4º do art. 33, regime diverso do fechado e substituição da pena por restritiva de direitos.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

II - PRELIMINARES

O processo instaurou-se e desenvolveu-se regularmente, não havendo nulidades a serem declaradas. Com efeito, o Juízo é competente, respeitou-se o direito de defesa e garantiu-se o contraditório do acusado.

Ainda, estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, inexistindo alegações das partes de outros vícios processuais.

Assim, verificada a regularidade do processo, passa-se à análise de mérito.

III - MÉRITO

No mérito, em observância ao princípio constitucional da motivação das decisões (art. 93, inc. IX da CRFB), densificado infraconstitucionalmente pelos arts. 11 e 489, § 1º, inc. IV do CPC – e aplicados ao processo penal na forma do art. 3º do CPP – passo a analisar todas as causas de pedir da acusação e teses defensivas. Destarte, passo ao exame da questão de fundo, aditando que a pretensão punitiva é improcedente.

Consente-se que simbolicamente a Lei 11.343, que revogou a Lei 6.368/76 "representa uma nova política na seara das drogas" (HASSON, Felipe. Drogas: Constituição, Democracia e Liberdade. Curitiba: Instituto Memória. Centro de Estudos da Contemporaneidade, 2015.p. 156).

Na seara do Direito Penal, afirmam Zaffaroni e Pierangelli: "todo direito quer regular a conduta humana em sociedade e comina para que os homens se adaptem a suas regulações. Portanto, também, o direito penal tem uma aspiração ética: aspira evitar o cometimento e repetição de ações que afetam de forma intolerável os bens jurídicos penalmente tutelados" (Manual de Direito Penal Brasileiro - Parte Geral. 10ª ed. São Paulo: Editora Revistados Tribunais, 2013. p. 95).

A definição de quais substâncias são consideradas ilícitas se encontra na Portaria SVS/MS n.º 344, de 12 de maio de 1998 (ver artigo 66 da Lei 11.343/06) e nesta definição se incluem todas as previstas no Anexo I (ver, p. ex., REsp.

1.444.537/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 12/4/2016, DJe 25/4/2016).

A materialidade da infração restou comprovada através dos seguintes elementos de

prova colhidos no Inquérito Policial: boletim de ocorrência (03/07), auto de exibição/apreensão (fls. 08/09), termos de depoimento (fls. 10/15 e 23), relatório final (fls. 51/55), laudo pericial (fls. 76/77 e 80/81), além da prova oral colhida nas duas fases da persecução penal.

No que tange à autoria, duvidosa sua atribuição ao réu, uma vez que o material probatório colhido não foi suficiente para a formação de seguro convencimento nesse sentido.

É certo que de acordo com o art. 155 do Código de Processo Penal, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. No caso dos autos, estes elementos informativos da investigação não foram corroborados pela prova produzida em contraditório.

Demais, adotando-se o conceito complexo do tipo de Hans Welzel, tem-se que ele apresenta um aspecto objetivo e outro subjetivo. Na ação penal típica, está implícito um juízo de valor. O tipo penal, deste modo, não é composto apenas por elementos objetivos, mas é também integrado por elementos normativos e subjetivos, que vão contornando o conteúdo material do injusto e identificando o bem jurídico tutelado. Em síntese, é a efetiva lesão ao bem jurídico que conduz o intérprete nos caminhos na tipicidade, como se minudenciará.

Vejamos:

Em solo policial, a testemunha Reizaldo de Jesus Fernandes Junior, policial militar, disse "Na data dos fatos, por volta das 17h30, encontrava-se na viatura prefixo I-21421 junto aos policiais SD-PM CARVALHO e SD-PM LANZA realizando uma operação na comunidade Vila Esperança, neste município de Cubatão/SP. Ao chegarem nas proximidades da travessa Santa Bárbara, visualizaram dois indivíduos em atitude suspeita (um de camiseta vermelha e o outro de agasalho preto). O indivíduo de camiseta vermelha portava uma sacola e, assim que a viatura policial foi avistada, ambos os indivíduos empreenderam fuga e adentraram em um bar que se encontrava com as portas entreabertas e, assim que invadiram o local, tentaram fechar as portas percebendo que os indivíduos se evadiram para o interior do bar, desembarcaram imediatamente da viatura e os perseguiram, vindo então a ingressar no estabelecimento, onde se depararam com os indivíduos que se evadiram inicialmente e um terceiro indivíduo. Procedendo à abordagem dos indivíduos, aqueles que inicialmente se evadiram foram identificados e qualificados como MATHEUS (que se encontrava de camiseta vermelha e foi avistado portando a sacola no momento em que se evadiram) e ALEX. Por sua vez, o terceiro indivíduo que já se encontrava no local era o proprietário do estabelecimento e foi identificado como WAGNER. Salienta que visualizaram a sacola que MATHEUS portava sobre uma mesa do bar assim que ingressaram no local em perseguição e, ao verificarem o seu conteúdo, constataram que a mesma continha uma quantidade considerável de entorpecentes em seu interior, consistindo em 231 invólucros de pedras amareladas aparentando ser crack (pesando 68g), uma porção de pedras amareladas aparentando ser crack (pesando 78g), um saco de pó branco aparentando ser cocaína a granel (pesando 256g) e R\$ 17,00 (dezessete reais) em espécie. Após a localização de sacola contendo entorpecentes, efetuaram vistoria no estabelecimento, porém não localizaram nada de ilícito no local. Diante dos fatos, conduziram e apresentaram os indiciados no 3º Distrito Policial de Cubatão para que as providências legais de polícia judiciária fossem tomadas."

Em Juízo, disse que se recorda vagamente dos fatos. O Réu estava junto com um outro sujeito. Estavam em operação em localidade conhecida como zona de tráfico.

Visualizaram o Réu e outro indivíduo, Alex, adentrando um bar e fechando as portas de aço. Realizaram o cerco do bar e adentraram. Foram abordados Matheus, Alex e o dono do Bar. Matheus e Alex estavam juntos. O local é conhecido como zona de tráfico, por isso o motivo da operação. Matheus e Alex, ao visualizarem a viatura, adentraram o bar e fecharam as portas. Não se recorda se Matheus e Alex estava portando sacola. Recorda-se das drogas, mas não se recorda se era sacola ou mochila. Salvo engano as drogas estavam com Matheus. Dentro da sacola ou mochila encontravam-se as drogas. Não se recorda se havia mais algo na mesa de bilhar. Quem fez a revista foi outro policial. Quem fez a primeira abordagem foram os outros

dois policiais. Após a abordagem havia droga. Recorda-se de crack mas não se recorda de outra droga. Não se recorda se havia dinheiro. Não conhecia Matheus ou Alex. Com o dono do bar (Wagner) não encontraram nada. Em princípio o dono do bar não falou nada. Já era de costume o pessoal adentrar o bar e usar droga escondido. Não se recorda se Matheus e Alex confessaram informalmente a prática do crime. Salvo engano havia quantidade de droga já embalada para venda. Matheus e Alex aparentavam normalidade, não estavam drogados. Só estavam Matheus e Alex, sem maiores movimentações na rua. Reconhece Matheus como sendo o sujeito que correu para dentro do bar. Dentro do bar não havia mais ninguém além dos três (Matheus, Alex e Wagner). O bar estava aberto. Ele possui duas portas, uma frontal e uma lateral. A porta lateral estava fechada. Quando adentraram pela porta frontal, Matheus fechou a porta. Não se recorda de encontrar algo em revista pessoal. Em solo policial, a testemunha Fernando Carvalho da Penha, policial militar, disse que Na data dos fatos, por volta das 17h30, encontrava-se na viatura prefixo I-21421 junto aos policiais SD-PM FERNANDES e SD-PM LANZA realizando uma operação na comunidade Vila Esperança, neste município de Cubatão/SP. Ao chegarem nas proximidades da travessa Santa Bárbara, visualizaram dois indivíduos em atitude suspeita (um de camisa vermelha e o outro de agasalho preto). O indivíduo de camiseta vermelha portava uma sacola e, assim que a viatura policial foi avistada, ambos os indivíduos empreenderam fuga e adentraram em um bar que se encontrava com as portas entreabertas e, assim que invadiram o local, tentaram fechar as portas percebendo que os indivíduos se evadiram para o interior do bar, desembarcaram imediatamente da viatura e os perseguiram, vindo então a ingressar no estabelecimento, onde se depararam com os indivíduos que se evadiram inicialmente e um terceiro indivíduo. Procedendo à abordagem dos indivíduos, aqueles que inicialmente se evadiram foram identificados e qualificados como MATHEUS (que se encontrava de camiseta vermelha e foi avistado portando a sacola no momento em que se evadiram) e ALEX. Por sua vez, o terceiro indivíduo que já se encontrava no local era o proprietário do estabelecimento e foi identificado como WAGNER. Salienta que visualizaram a sacola que MATHEUS portava sobre uma mesa do bar assim que ingressaram no local em perseguição e, ao verificarem o seu conteúdo, constataram que a mesma continha uma quantidade considerável de entorpecentes em seu interior, consistindo em 231 invólucros de pedras amareladas aparentando ser crack (pesando 68g), uma porção de pedras amareladas aparentando ser crack (pesando 78g), um saco de pó branco aparentando ser cocaína a granel (pesando 256g) e R\$ 17,00 (dezessete reais) em espécie. Após a localização de sacola contendo entorpecentes, efetuaram vistoria no estabelecimento, porém não localizaram nada de ilícito no local. Diante dos fatos, conduziram e apresentaram os indiciados no 3º Distrito Policial de Cubatão para que as providências legais de polícia judiciária fossem tomadas."

Em Juízo, disse que se recorda dos fatos. Quando estavam no caminho Santa Bárbara, visualizaram dois indivíduos que, após notarem a presença dos policiais, correram para dentro de um Bar. Os rapazes fecharam as portas do estabelecimento. Adentraram no local e em cima de uma mesa havia uma sacola com drogas. Wagner, pelo que se recorda, não tinha nenhuma relação com os rapazes e foi liberado. O local é conhecido como ponto de tráfico de drogas. Não se recorda de visualizar sacola ou mochila na mão dos Réus. Visualizaram sobre a mesa do bar, após entrar, uma sacola e drogas embaladas, prontas para venda. Recorda-se ser crack e, talvez, maconha. Recorda-se que existia maconha e crack, não cocaína, além de um pouco de dinheiro. Não conhecia previamente os rapazes. Com o dono do bar, Wagner, não foi localizado nada de ilícito. Não se recorda se Matheus confessou informalmente a prática da conduta. Matheus e Alex não estavam drogados. Próximo ao bar existe a rua, existiam as pessoas passando. O que chamou atenção foi os dois rapazes correndo para dentro do bar e fechando a porta. Quando chegaram a porta estava entreaberta. Não se recorda se foi encontrado algo em revista pessoal do Réu. Não se recorda de ver mochila ou sacola junto a Matheus. O que chamou atenção foi os rapazes entrarem no bar.

Em solo policial, a testemunha Felipe Thadeu Encenha Lanza, policial militar, disse que Na data dos fatos, por volta das 17h30, encontrava-se na viatura prefixo I-

21421 junto aos policiais SD-PM FERNANDES e SD-PM CARVALHO realizando uma operação na comunidade Vila Esperança, neste município de Cubatão/SP. Ao chegarem nas proximidades da travessa Santa Bárbara, visualizaram dois indivíduos em atitude suspeita (um de camisa vermelha e o outro de agasalho preto). O indivíduo de camiseta vermelha portava uma sacola e, assim que a viatura policial foi avistada, ambos os indivíduos empreenderam fuga e adentraram em um bar que se encontrava com as portas entreabertas e, assim que invadiram o local, tentaram fechar as portas percebendo que os indivíduos se evadiram para o interior do bar, desembarcaram imediatamente da viatura e os perseguiram, vindo então a ingressar no estabelecimento, onde se depararam com os indivíduos que se evadiram inicialmente e um terceiro indivíduo. Procedendo à abordagem dos indivíduos, aqueles que inicialmente se evadiram foram identificados e qualificados como MATHEUS (que se encontrava de camiseta vermelha e foi avistado portando a sacola no momento em que se evadiram) e ALEX. Por sua vez, o terceiro indivíduo que já se encontrava no local era o proprietário do estabelecimento e foi identificado como WAGNER. Salienta que visualizaram a sacola que MATHEUS portava sobre uma mesa do bar assim que ingressaram no local em perseguição e, ao verificarem o seu conteúdo, constataram que a mesma continha uma quantidade considerável de entorpecentes em seu interior, consistindo em 231 invólucros de pedras amareladas aparentando ser crack (pesando 68g), uma porção de pedras amareladas aparentando ser crack (pesando 78g), um saco de pó branco aparentando ser cocaína a granel (pesando 256g) e R\$ 17,00 (dezessete reais) em espécie. Após a localização de sacola contendo entorpecentes, efetuaram vistoria no estabelecimento, porém não localizaram nada de ilícito no local. Diante dos fatos, conduziram e apresentaram os indiciados no 3º Distrito Policial de Cubatão para que as providências legais de polícia judiciária fossem tomadas."

Em Juízo, disse que estavam em operação pela Vila Esperança, ocasião em que visualizaram 2 indivíduos, que correram para dentro de um bar. Era o motorista de viatura. Os outros 2 policiais efetivaram a abordagem no bar. Os 2 indivíduos estavam caminhando juntos e correram para dentro do bar. Ambos entraram no bar. Na hora em que chegaram ao bar as portas do estabelecimento estavam fechadas. Viu apenas uma sacola de drogas, sendo que a mesma estava na posse de Matheus, com uma camiseta vermelha. Dentro do bar, quando entraram, encontraram a sacola de Matheus. Recorda-se de encontrar crack embalado dentro da sacola. Não havia nada de ilícito no bar, exceto a sacola de drogas. Não se recorda se o Réu confessou informalmente a prática do crime. A viela que encontraram os Réus correndo era curta. De onde estavam dava para visualizar o bar. Havia uma terceira pessoa dentro do estabelecimento que era o dono.

Em juízo, a testemunha Wagner dos Santos de Jesus disse que não conhece o Réu Matheus Victor Xavier da Silva. No dia dos fatos havia uma senhora adquirindo cerveja em seu estabelecimento comercial. Logo após entrou um rapaz, solicitando a compra de refrigerante. Quando estava pegando o refrigerante, visualizou 2 policiais abordando um rapaz no lado de fora. Após uns 5 minutos os policiais colocaram outro rapaz para dentro do estabelecimento com uma sacola de drogas. O rapaz do refrigerante era o Réu, que chegou com uma bicicleta branca. Não falou para o Delegado que 2 rapazes entraram em seu estabelecimento e arremessaram uma sacola de drogas. Não leu o que assinou na Delegacia. Apenas pediram para assinar e assinou. Não foi coagido pelos policiais para assinar. O réu chegou no estabelecimento sozinho e os policiais colocaram outro rapaz dentro do bar com o réu. Após uns 5 minutos os policiais chegaram com outro rapaz. Não viu onde estava sacola de drogas. Os policiais militares é que falaram que estavam com uma sacola de drogas. Não viu onde os policiais encontraram a sacola contendo drogas. Somente quando os policiais vieram com outro rapaz é que falaram que encontraram a sacola de drogas. Não conhecia nenhum dos rapazes. No dia havia várias viaturas, umas 5 ou 6. A sacola de drogas veio com os outros policiais, que chegaram posteriormente, com o outro rapaz.

Em juízo, a equivocada testemunha Alex Gomes da Silva (homônimo), disse que não conhece o Réu. Encontra-se atualmente preso, condenado por tráfico de drogas. Não se recorda dos fatos de fevereiro de 2020, porque está há 6 anos preso. Não se

recorda de entrar em um bar juntamente com o Réu em fevereiro de 2020. Está preso e condenado desde 2016. Estava na colônia em Tremembé e antes na CDP de São Vicente. Em nenhum momento saiu da penitenciária desde 2016.

Em solo policial, o acusado Matheus Victor Xavier da Silva, permaneceu em silêncio e desejou se manifestar apenas em juízo acerca do fato.

Interrogado em juízo, disse que no dia estava de bicicleta, não estava correndo.

Entrou no bar para comprar um refrigerante e nesse tempo os policiais entraram e o abordaram. Nesse tempo que estava com os policiais apareceu um terceiro com uma sacola falando que a sacola era de sua propriedade. Também chegou um terceiro rapaz e apresentaram a sacola. Não conhecia o dono do bar.

Pois bem.

Finalizada a instrução processual, não ficou suficientemente comprovado que o réu praticou o crime descrito na denúncia.

A comprovação da natureza entorpecente da substância, imprescindível para o julgamento condenatório, é feita pela prova técnica, realizada por perito criminal, o que ocorreu no caso em tela (art. 158 do CPP).

Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o tipo do tráfico de drogas é tipo congruente simétrico, em que o tipo objetivo coincide com o tipo subjetivo, o que significa dizer que não se exige elemento subjetivo específico da mercancia. O tipo do art. 28 da Lei n. 11343/06, este sim, é tipo incongruente, em que o tipo subjetivo está além do tipo objetivo, o que equivale a dizer que se exige a comprovação do elemento subjetivo específico de consumir a droga que porta. Em outros termos, para a condenação no delito do art. 33 da Lei n. 11343/06, e não no art. 28, exige-se tão somente que se afaste, com segurança, a finalidade do consumo próprio, sendo desnecessária a prova da efetiva mercancia (STJ, REsp n. 1134610/MG, rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, j. 19.08.2010).

É certo que de acordo com o art. 155 do Código de Processo Penal, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. No caso dos autos, estes elementos informativos da investigação não foram corroborados pela prova produzida em contraditório.

E, a despeito de entendimento pessoal em sentido contrário quanto à suficiência dos depoimentos policiais para sustentar a condenação, curvo-me ao entendimento dominante em respeito à isonomia, estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência (art. 926 do CPC, aplicado na forma do art. 3º do CPP).

O depoimento dos policiais militares deve ser bem avaliado. É verdade que, sem pretender qualquer crítica, sabe-se que a atuação policial é uma atividade administrativa que se situa em um contexto de tensão de direitos fundamentais, de modo que seria ingenuidade recorrer acriticamente ao dogma da presunção de regularidade dos atos dos agentes dos poderes públicos, confundindo vigência (existência do ato e regularidade formal) com validade (conteúdo material constitucionalmente conformado).

Neste sentido, LUGI FERRAJOLI destaca que "diversamente dos outros ramos da administração pública, é uma atividade em contato direto com as liberdades fundamentais" (Diritto e Ragione. 1998, p. 798, em tradução livre).

Dogmaticamente, o art. 202 do CPP perluastra que "toda pessoa poderá ser testemunha". Ademais, demais, quanto à questão da suspeição de uma testemunha policial, temos que, dada a aplicação do princípio da igualdade (art. 5º, caput e inc. I da CRFB), a mesma estará sujeita tal qual como qualquer outra testemunha ao compromisso de dizer a verdade (art. 203 do CPP). Ora, "a qualidade da testemunha, seu meio de vida, sua profissão, sua reputação ou qualquer outro atributo pessoal não deve produzir efeito algum para impedir a sua atuação" (NUCCI, Guilherme de Souza. Provas no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 98).

A partir daí, parece evidente que o depoimento de policial somente poderia ser excluído da apreciação judicial se, desde logo, houvesse prova no sentido de que ele tivesse sido colhido em desrespeito às normas materiais – caso em que a prova deveria ser desentranhada dos autos (art. 157, CPP) –, ou às normas processuais, caso em que o ato seria nulo (art. 563 do CPP).

Entretanto, no caso em apreço, a palavra dos policiais merece a credibilidade dos

testemunhos em geral, sendo que não há elementos seguros e convincentes que afastam a confiabilidade de tais depoimentos, sobretudo porque o amplo acervo probatório arrolados nos autos encontra-se em consonância com os relatos dos agentes. Ocorre que dos três policiais ouvidos em juízo, somente o policial Felipe consignou ser a sacola contendo drogas de propriedade do Réu, mesmo no interior do estabelecimento (bar).

Entretanto, a versão do policial colide com a apresentada pelo Réu em sua autodefesa, corroborada pelo testemunho do Sr Wagner, dono do Bar. Assim, soa crível que o Réu estivesse no bar tão somente para comprar refrigerante e que a sacola não era de sua propriedade. Com efeito, os outros policiais militares afirmaram categoricamente que não viram o Réu com a sacola.

Observa-se que os testemunhos dos funcionários da polícia não são totalmente harmônicos e não descrevem os fatos com clareza, embora as palavras foram produzidas por pessoas isentas, que não tinham razões para prejudicar o acusado. Destarte, há dúvidas de que o comportamento perpetrado pelo réu se amolda perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/06, porque, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, "a noção legal de tráfico de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização" (STF, 1ª T. - HC nº 69.806/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Diário da Justiça, Seção I, 04/06/1993, p.11.012).

Não se pode olvidar, contudo, que os elementos produzidos na fase de inquérito não tem aptidão para sustentar uma condenação. Uma vez iniciada a ação penal, as provas ontologicamente repetíveis coletadas na fase inquisitorial não servem para fundamentar a condenação, pois prova precária produzida em sede policial sem o contraditório. A prova produzida na fase inquisitorial serve tão somente para subsidiar o convencimento do órgão acusador e permitir o oferecimento da denúncia, salvo se irrepetível. O Poder Judiciário existe e justifica-se em função da garantia à Jurisdição: como seu consectário lógico, exsurge a garantia de ser julgado com base na prova produzida dentro do processo, com todas as garantias do devido processo penal.

São atos de prova os atos dirigidos a convencer o juiz de uma afirmação para o julgamento final, no processo e a serviço do processo e da sentença, exigindo a estrita observância à publicidade, contraditório e imediação, praticados sob a visão e a supervisão do Juiz de Direito. Por outro lado, são atos de investigação aqueles dirigidos não a uma afirmação, mas a uma hipótese; estão a serviço da investigação preliminar e servem para formar um juízo de probabilidade, não a convicção do juiz; não exigem observância da publicidade, contraditório e imediação, princípios que podem ser restringidos; servem à formação da opinião delicti do acusador, demonstrando o *fumus comissi delicti* para justificar o processo (recebimento da ação penal) ou o não processo (arquivamento) e são praticados pelo Ministério Público ou polícia judiciária. São os atos de prova que podem fundamentar uma condenação, mas não os atos de investigação.

Entretanto, para que se sustente o édito condenatório mostra-se necessária a existência da certeza probatória quanto à materialidade e autoria delitivas, o que, especialmente neste último quesito (autoria), não se mostra no caso dos autos. Uma condenação, despida do necessário reconhecimento pessoal iria em sentido contrário a diretriz principiológica que determina que o Direito Penal deve ser interpretado de modo restritivo por envolver sérias imposições ao direito de liberdade, assegurando-se a presunção de inocência de todo cidadão, conforme previsão constitucional, já que "até mesmo a alta probabilidade servirá como fundamento absolutório, pois teríamos tão-só um juízo de incerteza que nada mais representa que não a dúvida quanto à realidade" (CAMARGO ARANHA, Adalberto José de. Da Prova no Processo Penal, p. 64).

Em que pese a gravidade dos fatos imputados, isto não é razão suficiente para assumir o risco do erro judiciário em que consistiria a condenação no presente caso, pois o conjunto probatório é demasiadamente frágil.

Nisto consiste o mandamento de otimização contido no princípio do *in dubio pro reo*. Em um modelo garantista, em que devem ser respeitados os princípios e garantias da pessoa submetida ao processo penal a fim de evitar abusos estatais que interfiram

em sua liberdade, dúvidas consideráveis devem ser resolvidas favoravelmente ao réu. Assim ensina LUIGI FERRAJOLI, ao concluir que “a certeza perseguida pelo direito penal mínimo está, ao contrário, em que nenhum inocente seja punido à custa da incerteza de que também algum culpado possa ficar impune” (Direito e Razão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 85).

O ônus da prova, no processo penal, incumbe ao órgão acusador (art. 156 do CPP) e não é possível a inversão desse ônus para exigir que o réu faça provada sua não culpa, visto ser esta última presumida por imperativo constitucional, elevada à categoria de cláusula pétrea (inciso LVII do art. 5º da CRFB).

Obtemperem-se, por oportuno, que factibilidade não é sinônimo de certeza. É possível sim que a versão apresentada pelo acusado seja falsa, porém, nada existe de concreto nestes autos que possa invalidá-la de modo absoluto, de tal forma que, como determina o sistema jurídico-penal brasileiro, em caso de dúvida (hipótese destes autos) deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo.

Por derradeiro, no caso dos autos, houve pedido de absolvição pelo Ministério Público. Logo, outra alternativa não há senão assim proceder, em virtude da não recepção do art. 385 do CPP pelo atual ordenamento constitucional, notadamente o sistema acusatório (art. 129, inc. I da CRFB).

Neste sistema processual (acusatório), o juiz é um sujeito passivo, rigidamente separado das partes, e o julgamento é um debate paritário, iniciado pela acusação, a quem compete o ônus da prova (art. 156 do CPP), e desenvolvido, com a participação da defesa, mediante um contraditório público, denominado de “ideologia processual democrática” por Michele Taruffo. Logo, “o sistema acusatório é marcado por configurar-se em um processo de partes, no qual há a completa dissociação entre a atividade de acusar e a tarefa de julgar, assim a iniciativa probatória compete exclusivamente às partes, mantendo-se o juiz como um terceiro imparcial” (SANTIAGO NETO, José de Assis. Estado democrático de direito e processo penal acusatório: a participação dos sujeitos no centro do palco processual. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2015, p. 214).

Por tal razão é que alguns dispositivos do Código de Processo Penal - acaso lidos sob a óptica da filtragem constitucional - não foram recepcionados, porquanto caracterizam inegável ranço autoritário/inquisitivo, a exemplo do art. 385; do art. 28, do art. 5º, inc. II (possibilidade do magistrado requerer a abertura de inquérito, oficiosamente); art. 13, inc. II (determinação de diligências, pelo magistrado, ainda que em fase de inquérito policial); art. 156, inc. I (determinação da produção de provas que entende ser relevantes e urgentes, de ofício); art. 209 (oitiva de testemunhas que não foram indicadas pelas partes, mas que entende ser relevantes à elucidação do caso concreto a ser sentenciado; art. 241 (possibilidade de realização, pela própria autoridade judiciária, de busca domiciliar); art. 311 (decretação de prisão preventiva de ofício pelo magistrado). Com o objetivo de adequar a lei processual penal ao modelo constitucional, o Projeto de Reforma do Código de Processo Penal (Projeto de Lei nº 7987/2010), atualmente em trâmite na Câmara dos Deputados, retira do Poder Judiciário nos moldes supra.

Assim, o juiz não pode atuar de ofício nem condenar sem acusação. E, por razões lógicas, resta ao Poder Judiciário encerrar a ação penal, em observância aos princípios da imparcialidade e da demanda ou inércia judicial, essenciais à realização do devido processo legal (art. 5º, LIV e LV da CRFB), com o escopo de evitar “o erro psicológico de crer que uma mesma pessoa possa exercer funções antagônicas, como acusar, julgar e defender; ou, em termos probatórios, ter iniciativa probatória, realizar o juízo de admissibilidade e gerir sua produção” (GOLDSCHMIDT, James. Problemas Jurídicos y Políticos del Proceso Penal. Barcelona: Bosch, 1935, p. 29).

Ademais, tal tese é reafirmada pela própria instituição, em parecer lavrado pelo eminente Sub-procurador da República no Resp 1.612.551/RJ.

Impõe-se, portanto, a absolvição do acusado MATHEUS VICTOR XAVIER DA SILVA, pela prática do crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei n.º 11.343/2006.

Ante o exposto, com fulcro no art. 386, inc. VII, do CPP, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão estatal deduzida na denúncia para ABSOLVER o réu MATHEUS VICTOR XAVIER DA SILVA, da prática dos crimes previstos no artigo 33, ''caput'', da Lei nº 11.343/06.

Em virtude do teor da presente decisão, notadamente no que tange ao regime de cumprimento de pena fixado, defiro o apelo em liberdade, na forma dos arts. 282, 311, 312 e 387, § 4º do CPP.

Custas na forma da lei.

Proceda-se à destruição das drogas (art. 72 da Lei 11.343/06). Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD) e a Secretária Nacional Antidrogas, para providências cabíveis, se caso.

Conforme Provimento CG nº 03/2017, que revogou o art. 1.272 das Normas da Corregedoria Judicial, as sentenças proferidas em autos eletrônicos não são mais registradas (art. 76, § 2º das Normas de Serviço).

Após o cumprimento, dê-se baixa e arquivem-se.

Sentença prolatada em audiência. Saem os presentes intimados.

Cubatão, 08 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA